

1500648-51.2021.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... a absolvição pela associação para o tráfico, em linha com a acusação. Com relação ao crime de tráfico, pugnou pela desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, em caso de condenação pelo crime de tráfico, pleiteou a aplicação da pena em seu mínimo legal; a atenuante da menoridade relativa; o reconhecimento do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena - Vara Criminal

Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500648-51.2021.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500648-51.2021.8.26.0621

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2181495/2021 - DEL.POL.LORENA, 18885577 - DEL.POL.LORENA, 589/21/204 - DEL.POL.LORENA, 2181495 - 02º D.P. LORENA, 589/21/204 - 02º D.P. LORENA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ GUILHERME DOS SANTOS GONCALVES

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de LUIZ GUILHERME DOS SANTOS GONÇALVES, qualificado nos autos, pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico (artigos 33, caput, e 35, ambos combinados com o artigo 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06), em razão dos fatos narrados na exordial acusatória, às fls. 84/86.

Oferecida a denúncia, o réu apresentou sua defesa preliminar (fls. 112/114). Não sendo caso de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 16/02/2022, designando-se audiência virtual de instrução e julgamento (fls. 115/117).

Em audiência foi ouvida uma testemunha de acusação, e realizado o interrogatório do

réu. Finda a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais orais na solenidade (mídia - fls. 176).

O Ministério Público requereu a procedência parcial da ação penal, com a condenação do acusado pelo delito do artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, e sua absolvição pela imputação remanescente (artigo 35, da mesma Lei).

A douta defesa, ao contrário da acusação, pugnou pela total improcedência da ação penal. Preliminarmente, sustentou a nulidade das provas, em razão de uma invasão de domicílio pelos policiais militares. No mérito, requereu a absolvição pela associação para o tráfico, em linha com a acusação. Com relação ao crime de tráfico, pugnou pela desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, em caso de condenação pelo crime de tráfico, pleiteou a aplicação da pena em seu mínimo legal; a atenuante da menoridade relativa; o reconhecimento do tráfico privilegiado; o afastamento da causa de aumento por envolvimento do adolescente; o regime menos severo; e o recurso em liberdade.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, malgrado respeito destinado à nobre defesa, não é o caso de acolher a preliminar invocada.

De fato, este Juízo não desconhece o entendimento que vem se formando no Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de prévia autorização do morador da residência para incursão policial, em respeito ao direito à inviolabilidade domiciliar.

Porém, entendo que a ação policial no caso em tela observou os limites da Constituição Federal.

Com efeito, diferentemente do que ocorre em outras situações, na hipótese dos autos, a entrada dos policiais militares no imóvel foi precedida pelo comportamento do réu, que arremessou um objeto e tentou fugir correndo para dentro do imóvel, sendo prontamente seguido pelos agentes da lei.

Logo, em virtude do estado flagrancial, expressamente excepcionada pela própria norma constitucional que garante a inviolabilidade domiciliar (artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal), mostrou-se perfeitamente legítimo o agir dos agentes públicos na espécie.

Insta salientar que o próprio Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre o assunto, em sede de repercussão geral (Tema 280), e estabeleceu as diretrizes para o controle judicial nessas hipótese, firmando a seguinte tese:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

Portanto, não se pode dizer que a conduta dos agentes públicos não foi amparada em fundadas razões, à luz daquela postura do próprio réu.

A propósito, em caso muito semelhante ao destes autos:

“TRÁFICO DE DROGAS - Preliminar de nulidade do feito, sob a alegação de invasão de

domicílio - Apelação buscando a absolvição ou desclassificação para o delito de uso de drogas ou reconhecimento de tráfico privilegiado e alegação de inconstitucionalidade da pena de multa - IMPOSSIBILIDADE - Preliminar afastada - Motivação para busca domiciliar se deu em razão da reação do apelante que tentou fugir - Ação policial dentro da legalidade, não se configurando violação de domicílio - Prova produzida suficiente para embasar o decreto condenatório para o tráfico de drogas - Apreensão de 15 porções de cocaína (15,92 gramas) e 15 porções de "crack" (12,58 gramas)- Ausência de elementos que indiquem que as drogas apreendidas fossem para uso próprio - Incabível a desclassificação - (...) - RECURSO NÃO PROVIDO". (TJSP; Apelação Criminal 1500202-49.2019.8.26.0126; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavalcheiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/06/2020; Data de Registro: 16/06/2020) (Sublinhado meu).

No mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva encontra-se cabalmente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/07), auto de exibição e apreensão (fls. 08/09), fotografias (fls. 23/27), laudos de constatação provisória (fls. 33/35) e definitivo (fls. 75/77), detectada a presença da substância "cocaína", que se encontra descrita na Lista F1 (Lista das Substâncias Entorpecentes) da Lista F (Lista das Substâncias de Uso Proscrito no Brasil) da Portaria ANVISA 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 143/2017 de 10/07/2017); bem como pelas provas orais contidas nos autos.

De igual modo, a autoria é certa, ao menos com relação ao crime de tráfico. Senão vejamos.

O policial militar Zaqueu Siqueira Azarias contou que estava em patrulhamento de rotina no local dos fatos, região já conhecida pelo intenso tráfico de drogas, quando observou um indivíduo (réu) saindo de uma residência. Este, ao ver a viatura, voltou correndo para o interior do imóvel. Diante da atitude incomum, o depoente desembarcou da viatura e saiu em sua perseguição, vendo claramente o momento em que o acusado arremessou um objeto no corredor, antes de entrar em um cômodo, no qual se encontrava o adolescente J.V.T.F.J, sendo ambos abordados. De acordo com o policial, nesse quarto, foram apreendidos entorpecentes, semelhantes àqueles arremessados pelo acusado anteriormente, além de outros apetrechos utilizados no vil comércio. Na posse de Luiz Guilherme também foi encontrado dinheiro. Questionado, disse que o increpado já era conhecido nos meios policiais pelo seu envolvimento anterior com o tráfico, assim como o inimputável. Zaqueu informou ainda, que o imóvel não possui moradores, sendo frequentemente utilizado por traficantes. Disse que há bastante tempo os dois são vistos naquele local (imóvel e adjacências), na posse de dinheiro, e que havia recebido informações de que o acusado estava saindo para entregar um "pote" (recipiente plástico contendo determinada quantidade de entorpecentes para venda), em determinado destino. Esclareceu que, embora não houvessem vestígios de moradores na casa, havia alguns móveis e roupas, e o banheiro estava funcionando.

Por sua vez, o réu negou os fatos. Contou que estava trabalhando à época, e havia acabado de receber seu pagamento (R\$ 550,00). Disse que havia dado duzentos reais à sua genitora, indo ao local comprar entorpecentes, sendo que, quando retornava, a viatura policial chegou e o abordou. O interrogando negou que tenha corrido para o interior do imóvel, afirmando que os 28 (vinte e oito) pinos de "cocaína" que estavam em sua posse destinariam-se ao seu próprio uso. Sobre o dinheiro encontrado em seu poder (R\$ 50,00), disse que era o troco da compra das drogas, e que sequer conhecia o menor até aquele dia. Questionado, declarou que já conhecia os policiais militares que lhe prenderam, não sabendo a razão para estes lhe acusarem de traficar. Afirmou que pagou duzentos e oitenta reais pelas drogas, e que as usaria em aproximadamente, três dias, dizendo que consome cerca de dez pinos por dia,

embora não se drogassem todos os dias. Por fim, disse que não entrou na casa, ficando com um agente da lei no corredor, enquanto outros policiais lá ingressaram e retornaram com o menor.

Essa, portanto, a prova oral.

Como se vê, é fato incontroverso que o réu possuía, ao menos 28 (vinte e oito) pinos de "cocaína", vez que o próprio assim admitiu em interrogatório, assim como a quantia de cinquenta reais.

O ponto nodal do processo, destarte, é desvendar o destino dos entorpecentes: se era para venda à terceiros, ou se, de fato, serviria ao próprio consumo de Luiz, tal como sustentou.

Pois bem. Analisando as circunstâncias do caso concreto, notadamente; a existência de informações anteriores dando conta de seu envolvimento com o vil comércio; o fato de ser flagrado na posse de razoável quantidade de drogas, tentado dispensá-las e evadir-se do local; e, ainda, a circunstância de estar na posse de dinheiro, sem origem lícita comprovada; tenho que os narcóticos se destinavam ao tráfico.

Aqueles que acompanham de perto as decisões deste Magistrado, bem sabem a credibilidade que costumo conferir às palavras dos policiais, sejam eles, militares, civis, federais, rodoviários federais, ou mesmo qualquer outro agente de segurança pública, seguindo, aliás, a maioria da jurisprudência dos nossos tribunais.

Confira-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça - STJ e do Tribunal de Justiça deste estado - TJSP:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. Agravo regimental não provido". (STJ; AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC; Relator: Ministro Ribeiro Dantas; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 05/03/2020; Data da publicação: 23/03/2020); e

"Apelação criminal. Tráfico de entorpecente. Materialidade delitiva demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão da substância entorpecente, laudo de exame químico-toxicológico e prova oral. Autoria comprovada pela palavra de testemunhas policiais - Depoimentos insuspeitos e harmônicos, suficientes para alicerçar o decreto condenatório - Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos - (...) Recurso desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 1514240-51.2019.8.26.0228; Relator: José Raul Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 22ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro: 30/04/2020) (Ênfase na reprodução).

E assim o faço, não só pela presunção de legitimidade que a própria lei confere aos atos por eles praticados, em razão da natureza pública da função que exercem, mas, também, por conta do total desinteresse deles em incriminar inocentes.

Afinal, como acreditar que policiais militares; cuja função precípua é impedir que

a legislação penal seja inobservada nas ruas, ou nas estradas federais, caso, também, da polícia militar e da rodoviária federal, respectivamente, ou mesmo, investigar a autoria daqueles que a violaram, como é o caso da polícia civil e federal; vá, eles próprios, violá-la, com o fito de incriminarem um inocente? Não faz qualquer sentido!

E não é só! Há, ainda, mais uma razão para se atribuir grande importância à palavra de tais agentes públicos: na maior parte das vezes, eles são os únicos dispostos a testemunharem sobre o que realmente viram sobre determinado crime.

Por motivos óbvios, ressalvado as pessoas ligadas ao criminoso por vínculo de parentesco, afinidade, ou mesmo amizade, poucas são as pessoas que se dispõem a testemunhar, seja em sede policial, ou mesmo em Juízo, a respeito de um determinado crime. E, infelizmente, é forçoso admitir que assim o fazem por um motivo justificável, ou, ao menos, compreensível: medo de represálias.

Decerto, conhecendo-se a triste realidade da violência urbana existente em um país pobre igual ao nosso, não é difícil imaginar o receio de um morador da periferia, onde também reside a maior parte dos traficantes e, por via de consequente, são instalados os pontos de venda de drogas nas cidades, se apresentar em sede policial e, depois, em Juízo, contar o que seu vizinho traficante faz em sua rua, por exemplo.

Nesta toada, negar a validade do testemunho de tais agentes de segurança implicaria negar vigência às leis penais. Na prática, estas restariam ineficazes.

Isso não significa, lado outro, de modo algum, que as palavras dos policiais e agentes públicos em geral tenham peso superior às demais. Pode-se dizer que, em se tratando de provas, não existe hierarquia entre elas, todas são relativas.

É a essência do sistema da persuasão racional, disposto no artigo 155, caput, do Código de Processo Penal, adotado atualmente:

“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Outro não é o entendimento do nosso Tribunal de Justiça:

“Embargos de Declaração. Oposição contra acórdão. Prequestionamento. Violação ao artigo 156 do CPP em face do que dispõe o artigo 203 do mesmo código. Inocorrência. Alegação de que não constou no decísium o critério de avaliação da credibilidade dos depoimentos de testemunhas que teriam se retratado em juízo. Omissão não configurada. Valoração da prova de acordo com seu conteúdo, coerência e harmonização com os demais elementos constantes dos autos. Sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP). Liberdade do juízo na ponderação das provas produzidas. Consideração dos elementos de convicção que se mostraram mais confiáveis e aptos a revelar a verdade dos fatos. Julgamento plenamente justificado. Embargos rejeitados”. (TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0005867-59.2002.8.26.0242; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Igarapava - Vara Única; Data do Julgamento: 10/11/2009; Data de Registro: 03/12/2009) (Sublinhado meu).

Fixada tal diretriz, observo que o caso ora em apreço, é mais um dentre tantos outros vistos no dia-a-dia forense, no qual o acusado tenta, em vão, desacreditar a fala dos agentes da lei, sem produzir sequer um início de prova da sua alegação, procurando assumir conduta menos grave (artigo 28, da Lei 11.343/06), salientando-se que a defesa sequer apresentou algum elemento a demonstrar, ainda que

precariamente, que o réu possuía ocupação lícita à época dos fatos, de modo a justificar o valor encontrado em seu poder.

Outrossim, o fato de eventualmente ser usuário de drogas, por si só, não impossibilita o acusado de praticar as condutas proibidas previstas no tipo penal em questão, muito pelo contrário, pois não raro usuários passam a vender drogas com o fim de financiar a própria dependência.

Seguem julgados com o mesmo entendimento:

“Apelações criminais. (...) Não há possibilidade de se desclassificar as condutas para mero porte de drogas, certo que a jurisprudência não descarta a figura do usuário/traficante. 2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o tráfico aos apelantes e apelado (...) 6-) Recursos presos”. (TJSP; Apelação Criminal 0001106-76.2017.8.26.0559; Relator: Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 05/12/2019; Data de Registro: 06/12/2019); e

“Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, e § 4º da Lei 11.343/06 (...) Condição de usuário não tem o condão de descaracterizar o crime do artigo 33 da referida norma, a qual possui conteúdo múltiplo e descreve diversas condutas, sendo o bastante para a sua caracterização a prática de apenas uma delas (...) Dado parcial provimento ao recurso”. (TJSP; Apelação Criminal 0002190-02.2017.8.26.0628; Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro: 02/12/2019) (Sublinhados meus).

Insta salientar que é desnecessário para configuração do crime de tráfico de drogas, a prática de atos efetivos de mercancia pelo agente, bastando a realização de uma das múltiplas ações previstas no tipo penal em voga, esclarecendo-se que a finalidade mercantil deve estar demonstrada pelas circunstâncias do caso, como quantidade das drogas e dinheiro, hipótese desses autos.

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Prisão em flagrante e firmes depoimentos dos policiais militares – Desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06 – Descabimento – Tipo penal que prevê diversas condutas – Desnecessidade da prova da efetiva mercancia – Condenação mantida – (...) Recurso não provido”. (TJSP; Apelação Criminal 1500932-98.2019.8.26.0566; Relator: Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019) (Ênfase na reprodução).

No mais, registre-se que a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Tóxicos foi exaustivamente demonstrada pela prova oral acima descortinada, na medida em que o réu foi surpreendido saindo, e depois tentando esconder-se no mesmo imóvel onde o menor foi flagrado manipulando entorpecentes, sem esquecer que as drogas apreendidas em seu poder eram idênticas àquelas manipuladas pelo inimputável.

Portanto, o caso é de condenação, nos exatos termos da inicial acusatória, quanto ao tráfico.

Por outro lado, com relação ao crime do artigo 35, caput, da Lei em assunto, o destino do acusado é a absolvição.

Com efeito, exige-se para caracterização do delito previsto no artigo 35, da legislação de drogas, não só a presença de dois ou mais agentes, mostrando-se imprescindível ainda, o animus associativo, a estabilidade, permanência e

organização do grupo, com funções pré-determinadas entre seus membros, bem como relação de hierarquia entre eles, o que não se comprovou nos autos, a despeito das notícias trazidas pela testemunha de acusação no sentido de que o réu e o adolescente eram vistos naquela região, conhecida pelo intenso tráfico de drogas, com frequência.

Anoto que, pela experiência deste Julgador, dificilmente restara comprovado esse tipo de associação criminosa, apenas com a prisão em flagrante de mais de um agente, à míngua de outros elementos probatórios que indiquem a estabilidade, permanência, hierarquia e/ou demais requisitos desse tipo penal acima mencionados.

Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico e associação. (...) Associação – provas insuficientes. O crime em tela exige a vontade de dois ou mais agentes se associarem (animus associativo) e sua consumação se dá com a reunião estável e permanente, dispensando a prática do crime-fim. Não se demonstrou, contudo, mínima organização e hierarquia entre eles o que, após cotejar todos os elementos analíticos inseridos nos autos, não emerge com clareza meridiana o vínculo associativo. (...) Recurso parcialmente provido, nos termos do v. Acórdão”. (TJSP; Apelação Criminal 0002107-90.2016.8.26.0443; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piedade - 1ª Vara; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017) (Ênfase minha).

Não por outro motivo, aliás, o próprio Ministério Público pugnou pela absolvição do réu em relação a tal imputação.

Passo à modulação penal:

O réu apresenta um passado de infrações penais completamente limpo (certidão de fls. 154/155). A quantidade de entorpecentes apreendida em sua posse (12,6 gramas, peso líquido), malgrado um pouco exagerada para um simples usuário, não extrapola a culpabilidade normal à espécie.

Destarte, e não lhe sendo desfavoráveis as demais circunstâncias judiciais, estabeleço a basilar no piso legal, no caso, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na fase intermediária, reconheço a atenuante da menoridade relativa, do artigo 65, inciso I, do Código Penal. Contudo, deixo de reduzir a sanção, por já se encontrar no mínimo legal.

Confira-se a Súmula 231, do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Outrossim, que deixei de reconhecer a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, vez que o réu, como se viu, negou sua responsabilidade penal pelos fatos aqui julgados, assumindo somente conduta mais branda, de mero usuário de entorpecentes, como forma de se ver livre da acusação da peça inicial.

Nesse sentido:

“Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de maconha – (...) Pleito para o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea – Relato dos fatos, acompanhado de teses defensivas e exculpatórias – Caracterização de ‘confissão qualificada’ pelo magistrado, que não admite a redução da pena – Inexistência de confissão para este Relator – (...) – Regime fechado – Recurso da ré Rosilei provido em parte e recurso do réu Vitor José provido em parte, em menor extensão”. (TJSP; Apelação Criminal 1500289-96.2019.8.26.0613; Relator (a): Xisto

Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Casa Branca - 2ª Vara; Data do Julgamento: 05/06/2020; Data de Registro: 05/06/2020) (Sublinhado meu).

Não existem agravantes.

Na última e terceira fase, embora a associação não tenha se confirmado, conforme fundamentando supra, o envolvimento do adolescente na conduta criminosa o foi.

Logo, aumento a pena à razão de 1/6 (um sexto), para 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multas, forte no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06.

Por outro lado, reconheço em seu favor a redutora disposta no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, por se tratar de réu primário, sem antecedentes, e à míngua de prova minimamente segura de integresse organização criminosa, ou se dedique às atividades dessa natureza.

Logo, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), considerando seu passado irretocável até aqui confirmado pela certidão criminal, finalizando-a em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, ausentes outras causas modificadoras.

Malgrado posição pessoal em sentido contrário deste Magistrado, certo é que a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou o entendimento de que a figura do tráfico privilegiado, não mais ostenta natureza hedionda, razão pela qual curvo-me a tal posição, prestigiando, assim, a uniformidade das decisões judiciais.

Neste sentido:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NA SUA FORMA PRIVILEGIADA. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. CRIME NÃO EQUIPARADO A HEDIONDO. ENTENDIMENTO RECENTE DO PLENO DO SUPREMO, TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC 118.533/MS. REVISÃO DO TEMA ANALISADO PELA TERCEIRA SEÇÃO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA Nº 1.329.088/RS. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO Nº 512 DA SÚMULA DO STJ. (...) 3. Acolhimento da tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, com o consequente cancelamento do enunciado 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça". (STJ, Recurso Repetitivo, Tema 600, Pet 11796/DF, Rel. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 23/11/2016).

Assim, fixada tal diretriz, em consonância com o quanto disposto no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, fixo o regime inicial aberto.

Por fim, fixo o dia-multa no piso legal, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo na data dos fatos, atualizado até o momento do seu efetivo pagamento, por serem parcas as informações acerca da situação financeira da acusada, forte nos artigos 49, § 2º, do Código Penal, e 43, da Lei 11.343/06.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar LUIZ GUILHERME DOS SANTOS GONÇALVES, qualificado nos autos, por violação do tipo penal previsto no artigo 33, § 4º, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, a uma pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, diária mínima; absolvendo-o quanto a imputação remanescente, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Embora também já tenha decidido de modo contrário no passado, rendo-me, uma vez mais, ao entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal Federal acerca da possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por

restritiva de direitos, na hipótese do reconhecimento da figura privilegiada do tipo (entendimento esposado no paradigmático Habeas Corpus nº 97.256/RS).

Saliente-se que a Resolução nº 5 do Senado, publicada em 16 de fevereiro de 2012, com efeito erga omnes, suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", inserida no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, consagrando o princípio constitucional da individualização da pena.

Desse modo, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, permanecendo a pena de multa, uma vez preenchidos os demais requisitos legais.

Destarte, como a pena privativa de liberdade supera 01 (um) ano, faz-se necessária a substituição por duas penas restritivas de direitos, segundo determina o § 2º, do artigo 44, do Código Penal.

Assim, a primeira pena restritiva será aquela prevista no artigo 43, inciso I, do Código Penal, a prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário-mínimo, a ser depositado em conta judicial, mediante a emissão da guia pertinente em cartório judicial, nos termos do Provimento CG nº 01/2013, deste E. Tribunal, futuramente revertida em favor de entidades credenciadas neste juízo.

A segunda pena restritiva de direitos será a prevista no artigo 43, inciso IV, do Código Penal, qual seja, prestação de serviço à comunidade.

De fato, as tarefas serão prestadas gratuitamente, de acordo com as aptidões dos réus, em entidades a serem designadas, devendo serem cumpridas à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, pelo período desta.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, considerando a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito. Expeça-se alvará de soltura, com urgência, em seu favor.

Custas pelo vencido.

Caso ainda não tenha sido realizado, encaminhem-se as drogas e demais apetrechos apreendidos às fls. 08/09, oficiando-se à autoridade policial para proceder à sua destruição.

Após o trânsito em julgado, decreto o perdimento da quantia apreendida em favor da União, ante as evidências de ser originária do vil comércio, conforme acima exaustivamente fundamentado, com fulcro no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.

A propósito:

"APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de DROGAS – Preliminar – Restituição de valor apreendido – Desacolhimento – Caderno processual que indica que o numerário questionado é proveniente da prática do tráfico de drogas – Inexistência de prova segura acerca da origem lícita do dinheiro apreendido – Perda em favor da união corretamente determinada – Inteligência dos arts. 62 e 63 da Lei n.º 11.343/06 – Preliminar rejeitada. (...) Condenação mantida. (...) – Recurso desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 1500220-88.2021.8.26.0356; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mirandópolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/11/2021; Data de Registro: 08/11/2021) (Ênfase minha).

Oportunamente, também após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências: a) Expeça guia de execução definitiva; b) Intime-se o acusado para pagamento da taxa judiciária, nos termos do artigo 479, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça; c) Oficie-se ao Tribunal

Regional Eleitoral deste Estado, conforme disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, c/c artigo 15, inciso III, da Constituição da República; d) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais para as anotações necessárias; e) Oficie-se a autoridade policial nos termos do artigo 72, da Lei 11.434/06, sobre a amostra guardada para contraprova; e f) Adotadas as cautelas legais, arquivem-se.

P.I.C

Lorena, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA